

0001423-53.2015.8.26.0233

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes contra a Ordem Tributária

Magistrado: Letícia Lemos Rossi

Comarca: Ibaté

Foro: Foro de Ibaté

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 16/03/2022

... jurisprudencial do e. TJSP:

Tráfico de drogas - Coesão e harmonia do quadro probatório - Circunstâncias do episódio que positivavam a traficância - Condenação mantida. Preliminar de nulidade - Cerceamento de defesa - Não ocorrência - Pleito de substituição de testemunha que não se enquadra nas hipóteses excepcionais elencadas no artigo 451 do Código de Processo Civil, aplicado por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ibaté

Foro de Ibaté

Vara Única

Rua Albano Buzo, 367, Ibaté - SP - cep 14815-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0001423-53.2015.8.26.0233 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001423-53.2015.8.26.0233

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes contra a Ordem Tributária

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HAASTARI PIMENTEL DE AZEVEDO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Letícia Lemos Rossi

Vistos.

HAASTARI PIMENTEL DE AZEVEDO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 1º, inciso II, da Lei 8.137/91, porque no período correspondente entre maio de 2011 a fevereiro de 2012, na Avenida São João, 180, Distrito Industrial, neste município e comarca, na condição de proprietário e administrador da empresa "Máster Comércio, Importação e Exportação de Cosméticos e Saneantes Ltda-ME", suprimiu tributo no valor de R\$ 21.650.918,90, mediante fraude à fiscalização tributária, omitindo operações em documento exigido pela lei fiscal.

A denúncia, fundada no inquérito policial, foi recebida em 29 de junho de 2017 (fls.182).

O acusado compareceu espontaneamente aos autos e apresentou defesa prévia (fls.234/263).

Saneado o feito, seguiu-se a instrução ouvindo-se uma testemunha de acusação e decretando-se a revelia.

Em alegações finais, o ilustre Representante do Ministério Público, à vista da

prova produzida, requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia, aguardando-se que o elevado prejuízo causado aos cofres públicos seja considerado para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, possibilitando-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Pugnou, por fim, a anotação do regime inicial aberto (fls. 352/355 e 523/524).

Já o ilustre Defensor reclamou pela absolvição, nos termos do artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal. Subsidiamente, requereu que em caso de condenação seja a pena fixada no mínimo legal, ou aplicada em fração de 1/8, bem como seja a pena privativa de liberdade convertida em restritiva de direitos (fls. 469/510 e 528/531).

Em síntese, o RELATÓRIO.
DECIDO.

Inicialmente, verifico que não há que se falar em nulidade dos atos processuais.

É assente na jurisprudência que o comparecimento espontâneo do réu supre a necessidade de citação. Às fls. 216, há juntada de procuração com poderes para atuar no feito em questão, o que pressupõe soubesse o réu de suas acusações, mesmo porque cabe ao advogado orientar seu cliente sobre o processo em curso.

Nesse sentido, colaciono julgado do STJ:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CITAÇÃO. NULIDADE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO ACUSADO. NOMEAÇÃO DE ADVOGADO COM PODERES ESPECÍFICOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. O reconhecimento de nulidade no processo penal exige a demonstração do efetivo prejuízo à defesa.

2. O comparecimento do acusado, com a constituição de defensor, sana eventual vício na citação pessoal.

Recurso ordinário desprovido (RHC 51.725/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 24/11/2017).

No mais, o prazo preclusivo para indicação de testemunhas é a defesa prévia, ocasião em que o réu pode arrolar as testemunhas que lhe convier à defesa. Sobre a substituição de testemunhas, importante registrar que o artigo 397 do CPP permitia a substituição, caso a testemunha não fosse encontrada. No entanto, tal dispositivo foi revogado pela Lei nº 11.719/08, de forma que a substituição de testemunhas se dará apenas nas hipóteses do artigo 451 do CPC, com aplicação subsidiária no processo penal.

Assim, forçoso reconhecer que o réu não tem o direito à livre substituição das testemunhas, devendo fazer sua escolha no momento de sua defesa, podendo haver a substituição apenas em casos específicos de impossibilidade por morte, enfermidade ou não localização.

Senão vejamos, entendimento jurisprudencial do e. TJSP:

Tráfico de drogas – Coesão e harmonia do quadro probatório – Circunstâncias do episódio que positivavam a traficância – Condenação mantida. Preliminar de nulidade – Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Pleito de substituição de testemunha que não se enquadra nas hipóteses excepcionais elencadas no artigo 451 do Código de Processo Civil, aplicado por analogia, em observância ao artigo 3º, do Código de Processo Penal – Precedente do C. STJ. (...) Apelo defensivo improvido, rejeitada a preliminar (TJSP; Apelação Criminal 1500183-11.2019.8.26.0557; Relator (a): Mauricio Valala; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Colina - Vara Única; Data do Julgamento: 16/03/2021; Data de Registro: 16/03/2021) (g.n.).

Na sequência, afirma a defesa que foi obstado o exercício de auto defesa pela decretação da revelia do réu, sem motivo. No processo penal, a possibilidade de revelia está positivada no artigo 367 do CPP, portanto, se o réu mudar de residência sem comunicar novo endereço, o processo seguirá seu curso normal. In casu, foi expedida carta precatória para interrogatório do réu, entretanto, o cumprimento foi negativo (fls. 303), nessa toada, já havendo a oitiva da única testemunha de acusação, natural o encerramento da instrução para a fase de alegações finais. Não cabe ao juízo deliciar pela localização do réu que tem o ônus de manter endereço atualizado e acompanhar o andamento do feito.

Finalmente, o réu reclama de nulidade pela não intimação para diligências. No processo penal, vige o princípio do "pas de nullité sans grief" de forma que caberia ao réu indicar as diligências que tende necessárias para o exercício de seu direito de defesa. A mera alegação genérica e sem indicar o prejuízo concreto não é apta a gerar nulidades.

Ao que se vê, o réu busca tumultuar o regular andamento do feito. Comparece de forma espontânea e reclama ausência de citação; pretende substituir testemunhas sem amparo legal e alega cerceamento; frustra intimação para interrogatório e se opõe à revelia; por fim, alega que não lhe foi oportunizado o requerimento de diligências e não justifica a relevância.

Enfim, por todo o relato e fundamentado não há como acolher as preliminares de nulidade.

Finalmente, com relação ao alegado bis in idem, as ações 0000044-77.2015.8.26.0233 e 0000184-43.2017.8.26.0233 foram ajuizadas segundo as informações encaminhadas pela Fazenda Estadual e estão em estágios diversos de tramitação, a primeira já com sentença proferida, o que inviabiliza a unificação dos processos. Além disso, a unificação das penas poderá ser considerada na fase de execução criminal, conforme previsto na lei de execuções penais, sem prejuízo ao réu.

Sobre a questão a defesa impetrou o HC nº 2083228-38.2020.8.26.0000 cuja ordem foi denegada pelo i. Relator no Tribunal de Justiça de São Paulo.

No mérito, procede a pretensão acusatória.

Trata-se de crime contra a ordem tributária, previsto no artigo 1º, inciso II, da Lei 8.137/90 (omitindo operações em documento exigido pela lei fiscal).

A materialidade do delito vem demonstrada pelo relatório circunstanciado das infrações (fls. 07/10), pelo auto de infração e imposição de multa (fls. 20/23), e pelas demais provas produzidas em juízo.

E a autoria é inconteste.

A testemunha Sangia contou que atua como fiscal e que a empresa deixou de apresentar os livros fiscais no formato digital no período de fevereiro a outubro e depois em novembro a fevereiro apresentou os valores zerados sem nenhuma escrituração do documento fiscal. O crédito da empresa tem que ser fundado na escrituração de documentos fiscais e, além disso, as notas foram verificadas e com isso 97% das notas eram notas inidoneas. A acusação se deu por conta da falta de escrituração e ainda que houvesse a escrituração os documentos seriam inidôneos. Pelo o que se lembra não houve apresentação de recurso administrativo. A fiscalização de uma empresa se inicia por meio de uma ordem de serviço e o trabalho é executado de acordo com a ordem de serviço expedida, sendo os serviços bem variados, e durante essa fiscalização houve o levantamento de dados do contribuinte e análise dos documentos e notas.

O réu foi revel.

Pelo quanto relatado pela testemunha, não restam dúvidas, diante de todo o conjunto probatório, de que o acusado praticou as condutas descritas na denúncia, ante a comprovação de que exercia a administração empresa "Máster Comércio, Importação e Exportação de Cosméticos e Saneantes Ltda-ME", sendo, portanto, responsável pela higidez dos negócios praticados.

A empresa gerida pelo denunciado causou prejuízos à ordem econômica, diante de sucessivos desfalques, referentes à ausência de recolhimento de tributos em alta quantia.

Portanto, ao contrário do que alega a defesa, tanto das provas documentais como testemunha extrai-se de modo muito claro que ocorreu a fraude, mediante utilização de notas fiscais inidôneas e ausência de escrituração de livros, valendo-se o acusado desses artifícios grosseiros para fraudar o fisco, reduzindo a arrecadação tributária.

Ainda, conforme já mencionado, as provas coligidas aos autos comprovam que o acusado era a efetivamente administrador da empresa, recaindo sobre ele a responsabilidade penal, pela ausência de escrituração de livros fiscais e assim ter deixado de recolher o devido tributo.

Cumprе ressaltar que a existência de contador responsável pela escrituração/emissão de notas fiscais não exime os administradores de fato da responsabilidade penal, até porque o lucro da sonegação beneficiaria somente os acusados.

Resta apurar a existência do dolo, indispensável para a caracterização do delito.

Com efeito, a Lei nº 8.137/90 criminalizou a sonegação de impostos, que anteriormente constituía apenas infração civil/tributária. Porém, verificada a ocorrência de infração administrativa não está configurado automaticamente o tipo penal, visto que é necessária a presença do elemento subjetivo da conduta, qual seja a vontade livre e consciente de sonegar o tributo.

In casu, não é possível afastar o dolo na conduta do réu.

Não se trata de uma conduta isolada, o que poderia fazer crer se tratar de mera irregularidade ou erro contábil, mas, ao contrário, se repetiu no período de maio de 2011 a fevereiro de 2012, omitindo-se nesse tempo a escrituração de livros obrigatórios e com emprego de notas fiscais inidôneas, além de ter produzido supressão significativa no valor do tributo (R\$ 21.650.918,90).

Nesse contexto, não há como se negar a existência do dolo, isto é, da vontade livre e consciente de sonegar o tributo, sendo típica a conduta praticada pelo acusado.

Outrossim, de qualquer ângulo que se analise o caso em foco, não é possível vislumbrar atipicidade na conduta do réu, além do mais, todo o trâmite administrativo foi respeitado e cumprido.

Assim, é típica a conduta do acusado e sua condenação é medida de rigor.

Passo a dosimetria da pena

Em que pese o réu responda a outros processos criminais, é formalmente primário e de bons antecedentes (fls. 514/519).

Na primeira fase, atendendo as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, possível a elevação da pena em razão de culpabilidade exacerbada pelo grande

prejuízo causado à Fazenda Pública pela supressão de impostos em valor muito elevado (R\$ 21.650.918,90), assim, fixo a pena base em 2 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa, a qual torno definitiva por ausência de causas de oscilação.

Preenchidos os requisitos legais, previstos na forma do artigo 44, §2º, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade imposta por duas restritivas de direito, consistente em prestação pecuniária de três salários mínimos, a ser destinada a instituição de fins sociais, e prestação de serviço à comunidade, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação.

Em caso de conversão, fixo o regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, que se mostra adequado à consecução das finalidades da sanção penal, nos termos do artigo 33, §2º, alínea "c", do Código Penal.

Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a acusação para CONDENAR o réu HAASTARI PIMENTEL DE AZEVEDO, como incurso no artigo 1º, inciso II, da Lei nº 8.137/90, à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 11 dias-multa, no valor unitário mínimo. Substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, nos termos supra.

O réu poderá recorrer em liberdade, pois assim respondeu a todo o processo.

Custas na forma da lei.

Oportunamente, promova-se o registro da condenação definitiva do acusado no sistema informatizado da serventia, comunicando-se o Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (I.I.R.G.D.).

Ibaté, 16 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA